

1500573-54.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500573-54.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500573-54.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082206/2022 - DEL.POL.ITAPEVI, 23847995 -

DEL.POL.ITAPEVI, 2082206 - DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATANAEL FERNANDES JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

NATANAEL FERNANDES JUNIOR, qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no art. 309, caput, da Lei n.º 9.503/97 (CTB), e no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, no dia 25 de março de 2022, às 02h19min, na Rua Visconde de Mauá, n.º 10, Jardim Maristela, nesta cidade e Comarca de Itapevi, o réu dirigiu veículo automotor em via pública, sem a devida habilitação ou permissão para dirigir, gerando perigo de dano.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o réu trazia consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (f. 96) e apresentou defesa prévia (f. 100-104).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 28 de junho de 2022, na qual também restou indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa (f. 114-116).

O réu foi citado, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo.

Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas, tendo-se interrogado o réu ao final (f. 146). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (f. 144-145).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática das infrações penais previstas no art. 309, caput, da Lei n.º 9.503/97 (CTB), e no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é procedente.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória.

A confissão, aliás, restou corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 08, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes em posse do acusado.

A substância entorpecente foi submetida a exame pericial (f. 91-93), sendo que o resultado foi positivo para "maconha", droga de uso proscrito no Brasil.

A existência do delito de trânsito está demonstrada pelo boletim de ocorrência de f. 02-05 e pelos depoimentos de f. 15-17.

Quanto à autoria, tem-se que os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram contestes nos pontos essenciais e confirmaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Relatam que estavam em operação de bloqueio de trânsito e deram ordem de parada ao acusado. Ele os ignorou e empreendeu fuga em alta velocidade, quase atropelando um sargento que estava no local e ultrapassando sinal vermelho de semáforo. Começaram o acompanhamento do veículo e conseguiram abordá-lo numa rua sem saída. Dentro do veículo havia três pessoas. Indagado, o réu afirmou que apenas não parou porque não possuía carteira de habilitação. As duas mulheres que estavam no banco de trás estavam nervosas e disseram que pediram a todo momento pra ele parar o veículo, sendo que ele recusou porque disse haver uma arma de fogo lá dentro. Revistaram, então, o veículo, e no porta-malas encontraram uma mochila que continha drogas em seu interior.

E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria dos policiais militares de incriminar injustamente o acusado. Assim, seus depoimentos merecem credibilidade e são valiosos para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas nos depoimentos dos policiais militares, permitem presumir que as drogas apreendidas com o acusado se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

As testemunhas Pamela Natália Gouveia de Almeida e Nicolly Christine Alves da Silva, por sua vez, também foram uníssonas e corroboraram a prática dos crimes narrados na exordial acusatória. Dizem que o acusado era conhecido de uma delas e, no dia dos fatos, encontraram-no dirigindo um veículo na rua e pediram carona. Entraram no veículo e, perto do terminal de ônibus de Itapevi, havia uma blitz. Os policiais deram ordem de parada, e o réu desobedeceu e fugiu do local. Iniciada a perseguição pela via pública, elas pediam para que ele parasse o veículo, e ele dizia que não podia parar porque tinha uma "peça" dentro do carro. Depois da abordagem pela polícia, descobriram que ele tinha drogas no porta-malas.

Importante ressaltar que o perigo concreto de dano que causou o réu ao dirigir o

veículo - sem habilitação para tanto, em alta velocidade, incompatível com a via pública, a qual possuía transeuntes em virtude de uma estação de transporte público nos arredores - foi confirmado pelas quatro testemunhas ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório.

As testemunhas, inclusive, afirmaram que acusado dirigiu em alta velocidade e, ao empreender fuga da blitz, quase atropelou um dos policiais que estava no local. Uma delas, aliás, asseverou que o réu desrespeitou a sinalização semafórica para possibilitar a fuga.

Sublinhe-se, no ponto, que, na fase inquisitiva, as testemunhas já haviam afirmado que o acusado dirigira em alta velocidade e quase atropelara um policial (f. 15, 17, 19 e 20).

O perigo de dano concreto em relação ao delito de trânsito resta, pois, bem caracterizado na presente hipótese.

Nesse sentido:

DESOBEDIÊNCIA, DESACATO, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO, COM PERIGO CONCRETO DE DANO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas bem amplamente demonstradas.

Policiais militares que confirmaram que o acusado, depois de receber ordens de parada, empreendeu fuga com uma motocicleta em alta velocidade, realizando manobras perigosas em desrespeito a sinais de trânsito e semafóricos, até que perdeu o controle e caiu, oportunidade em que foi abordado e passou a proferir ofensas contra os milicianos e resistiu à prisão, causando ferimentos em um dos agentes da lei. Lesões sofridas pelo policial retratadas em laudo pericial. Acusado que negou os delitos em solo policial, admitindo apenas que não é habilitado, mas, em juízo, tornou a dizer que não possui CNH, confessou a fuga em velocidade, as ofensas e a agressão para que não fosse preso, asseverando que estava de "saidinha" e sob o efeito de álcool, o que o deixou nervoso. Confissão judicial plena que está em sintonia com os demais elementos de convicção dos autos. Depoimentos dos policiais oficiais que não se mostram despropositados ou eivados de vícios. Delito do CTB bem caracterizado em sendo evidente o perigo de dano em uma fuga em alta velocidade com desrespeitos a sinais de trânsito e sinalização semafórica. (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal n.º 0010576-68.2015.8.26.0635, 15ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Gilda Alves Barbosa Diodatti, julgado em 15/05/2020) Assim, tanto a materialidade dos crimes, quanto a autoria delitiva decorrem do conjunto probatório.

No que tange à aplicação da circunstância privilegiadora, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, revendo posicionamento anterior e tendo em vista os recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, não vislumbro inconstitucionalidade na incidência da causa de diminuição de pena.

Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo".

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos

crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa. 25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação da privilegiadora ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, todavia, é incabível a aplicação da forma privilegiada do tráfico, eis que não observados cumulativamente todos os requisitos para sua aplicação.

Com efeito, o réu é reincidente específico, de acordo com a certidão de f. 137-139, de modo que não preenche o primeiro requisito.

Inviável, nesses termos, a incidência da circunstância privilegiadora.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes e pelo crime tipificado no art. 309 do CTB.

Nessa conjuntura, verifica-se que há subsunção das condutas do acusado aos tipos penais previstos no art. 309 do CTB e no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, com vontade e consciência, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, e, ainda, trazia consigo as porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar.

Os fatos são ilícitos, pois reprovados pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

O denunciado era maior de 18 anos de idade (imputável), tinha potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhe exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu NATANAEL FERNANDES JUNIOR, já qualificado, nas sanções do arts. 309 do CTB e 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: "O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser

encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais" (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP - "personalidade e conduta social do agente". Outrossim, tem-se que "a natureza e a quantidade da substância ou produto" podem ser analisadas no contexto das "circunstâncias" do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da "preponderância" prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima - personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena - ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, o réu ostenta antecedentes criminais, pois possui duas condenações com trânsito em julgado, sendo que uma delas será valorada na segunda fase da dosimetria.

Além disso, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deve-se levar em conta, para a fixação da pena base, o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, notadamente, no caso em tela, a expressiva quantidade da substância apreendida (1,7 kg de maconha - f. 91-93).

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis ao réu, ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, havendo uma circunstância judicial negativa em relação aos dois crimes (maus antecedentes) e uma circunstância judicial preponderante negativa em relação ao crime de tráfico (circunstâncias do crime), fixo as penas bases em: a) 06 meses e 22 dias de detenção para o crime do art. 309 do CTB; e b) 07 anos e 06 meses de reclusão - e 750 dias-multa para o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, tendo em vista que,

conforme certidão de f. 137-139, o acusado cometeu os crimes em tela depois de ter sido condenado definitivamente por outro delito, tal como dispõem os arts. 63 e 64, inciso I, ambos do CP.

Reconheço, também, a atenuante da confissão espontânea, em virtude de o réu ter confessado, em juízo, a prática de ambos os delitos (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP).

Assim, em consonância com o C. Superior Tribunal de Justiça, que pacificou, no julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS (DJe 4.9.2012), o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do CP, deixo de exasperar ou diminuir as reprimendas, mantendo-as no mesmo patamar da pena-base fixada, provisoriamente. Por fim, na última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, fixo as reprimendas, agora definitivamente, em: a) 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção para o crime do art. 309 do CTB; e b) 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão – e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Aplicando-se a regra do art. 69 do CP, fica a reprimenda assim estabelecida: 7 anos e 6 meses de reclusão e 6 meses e 22 dias de detenção – e 750 dias-multa.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira do denunciado, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

De acordo com o art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais.

Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo ao acusado.

Mantenho a custódia cautelar do denunciado, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo o réu na prisão onde se encontra. Expeça-se a guia de execução provisória.

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Determino a perda dos bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006.

Custas pelo réu (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, "a"), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhe fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeça-se a guia de execução definitiva;

(c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
(d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e
(e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapevi, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA